

1508166-93.2021.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Marina Freire

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... muito conhecido pela prática do tráfico de drogas, observou a ré caminhando pela Rua Treze, bem como notou que ela dispensou um maço de cigarros e passou a andar rapidamente, motivo pelo qual procedeu à abordagem, momento em que ela afirmou que os policiais não conheciam sua história e, se encostassem as mãos nela, iriam morrer. Acrescentou que vistoriou o maço de cigarros, nele ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508166-93.2021.8.26.0071

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Autor do Fato:

ANA PAULA CARVALHO

Juíza de Direito: Dra. Marina Freire

Vistos.

ANA PAULA CARVALHO, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 1º de setembro de 2021, por volta das 13h29, no cruzamento da Avenida Cruzeiro do Sul com a Rua Treze, Jardim Country Club, nesta cidade e Comarca de Bauru, trazia consigo, para consumo pessoal, 0,68 g de entorpecente conhecido como cocaína, dividido em 4 porções, e 21,86 g de entorpecente conhecido como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, segundo a denúncia, que ANA PAULA CARVALHO foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 329 do Código Penal, porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima mencionadas, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

Oferecida a denúncia (fls. 1/3), por decisão de fls. 38/40 foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, bem como determinada a citação da ré.

A ré foi citada à fl. 61. Em audiência, a defesa foi apresentada e a denúncia foi recebida, como também dado início à fase de instrução, na qual foram ouvidas duas testemunhas comuns. Ao final, a ré foi interrogada (fls. 64/65-mídia).

Encerrada a fase de instrução, as partes passaram às alegações finais. O representante do Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, pois entendeu comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos (fls. 90/92).

Em outro ângulo, a Defesa rogou pela absolvição da ré sob o argumento de fragilidade probatória. Ainda, sustentou a atipicidade material em razão da insignificância no tocante ao crime do artigo 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação de regime inicial aberto e aplicação da pena de advertência (fls. 96/106).

É o relatório.
DECIDO.

Trata-se de ação penal instaurada para a apuração do crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 e do delito contido no artigo 329 do Estatuto Repressivo.

O conjunto probatório é contundente e apto a dar arrimo à procedência da denúncia.

A materialidade delitiva restou sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 4/6, auto de exibição e apreensão de fl. 11, laudo toxicológico definitivo de fls. 14/18, bem como pela prova oral amealhada nos autos.

A imputação da autoria dos delitos à ré é igualmente inarredável, pois foi fruto da prova colhida em Juízo, sob a égide do princípio do devido processo legal, assegurando, de forma imperiosa, o contraditório e a ampla defesa.

Em seu interrogatório, a ré negou a prática criminosa. Disse que, no dia dos fatos, estava indo a um estabelecimento comercial quando os militares passaram com a viatura e lhe perguntaram o que carregava na mão, tendo respondido que era cédula de R\$ 50,00, momento em que um policial desembarcou e afirmou que ela iria ser conduzida. Falou que um militar a derrubou ao chão e outro pisou na região de suas costas e cabeça, bem como tentou colocá-la na viatura, tendo sido novamente atingida ao tentar sair do veículo. Mencionou que foi socorrida em hospital e afirmou que havia sido agredida pelos policiais. Esclareceu que sequer foi algemada na via pública e apenas viu os entorpecentes na delegacia de polícia. Aduziu que as fotografias acostadas aos autos comprovam as agressões, é portadora de doença, reside no bairro há 33 anos e depois dos fatos não teve outros problemas (fls. 64/65-mídia).

O policial militar Ícaro de Mello Roque relatou que, em patrulhamento pelo Bairro Ferradura Mirim, local muito conhecido pela prática do tráfico de drogas, observou a ré caminhando pela Rua Treze, bem como notou que ela dispensou um maço de cigarros e passou a andar rapidamente, motivo pelo qual procedeu à abordagem, momento em que ela afirmou que os policiais não conheciam sua história e, se encostassem as mãos nela, iriam morrer. Acrescentou que vistoriou o maço de cigarros, nele encontrou porções de estupefacientes, deu voz de prisão à ré e determinou que ela colocasse as mãos para trás, quando a ré partiu em sua direção e então se defendeu, tendo sido necessário derrubá-la ao chão para tentativa de contenção, porém ela apresentou resistência e desferiu um chute em seu peito. Asseverou que seu colega de farda conseguiu imobilizar e algemar a ré. Contou que a ré passou a chutar a viatura e gritar, além de impedir o fechamento do veículo, colocando seu pé para fora. Explicou que não conhecia a ré, tomou ciência do nome dela apenas na delegacia de polícia e não a abordou posteriormente (fls. 64/65-mídia).

No mesmo sentido, o policial Eduardo Moreno Barbosa narrou que, na data dos fatos, em patrulhamento pela Rua Treze do Bairro Ferradura Mirim, viu a ré dispensando um maço de cigarros e acelerando os passos assim que constatou a presença da viatura, razão pela qual procedeu à abordagem, sendo que a ré estava alterada, não quis se identificar e ofendeu ambos os policiais, além de afirmar que eles sofreriam consequências caso encostassem as mãos nela; ato contínuo, seu colega de farda verificou o maço de cigarros, localizando porções de cocaína e maconha. Reportou que, após ser dada voz de prisão, a ré partiu em direção da equipe e tentou agredir seu colega de farda com soco, havendo necessidade do uso de força moderada, jogando-a ao chão, e algemas. Disse que a ré chutou a viatura durante todo o trajeto e apresentava machucado no pé, tendo sido socorrida em nosocômio (fls. 64/65-mídia).

Ao que se extrai das provas documental e oral colhidas nos autos, bem como observada a dinâmica dos fatos, não persistem dúvidas no tocante à responsabilidade da ré pela prática dos delitos.

Ora, os policiais militares foram uníssonos e categóricos em afirmar que efetuavam patrulhamento de rotina, notaram que a ré dispensou um maço de cigarros ao chão e passou a caminhar rapidamente, momento em que procederam à abordagem, localizaram drogas no objeto arremessado e a ré resistiu à prisão, empregando violência e ameaça contra os agentes públicos.

A propósito, é importante salientar que nada há nos autos capaz de retirar o valor probatório dos depoimentos dos policiais, os quais apresentaram a mesma versão em ambas as fases do procedimento, razão pela qual merecedores de credibilidade. A essência dos depoimentos dos militares revelou-se, em sua substância, uniforme e factível em Juízo.

De fato, não podem ser desconsiderados os depoimentos dos policiais, servidores públicos cumpridores de seu dever, já que foram compromissados como qualquer outra testemunha e não possuem interesse em incriminar a ré. Necessário ressaltar que a função da Polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente quando não há qualquer relação anterior entre estes e os agentes. Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos militares. Por tal razão, não merecem ver desprestigiadas suas palavras somente pelo fato de pertencerem ao quadro da Polícia. Nesse sentido:

“Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais militares com fundamento tão-somente na respectiva condição funcional, já que eles foram submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades. [...] Ressalte-se que, como é cediço, policiais não estão legalmente impedidos de depor em processos nos quais tenham participado da fase investigativa, revestindo-se suas palavras de relevante valor probatório, mormente quando prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório. Ademais, nada de concreto foi trazido aos autos no sentido de infirmar os seus relatos, sendo certo que não teriam razão alguma para imputar a prática de infração tão grave a pessoas que sabem ser inocentes.” (TJSP. 11ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0001971-89.2017.8.26.0530. Relator: Salles Abreu. Data do julgamento: 3 de outubro de 2018).

Dessa forma, a análise do conjunto probatório indica inexistir fragilidade probatória a ponto de propiciar a absolvição da ré.

No tocante ao crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, não fosse pela prova oral produzida, as porções de cocaína e maconha (laudo pericial de fls. 14/18)

apreendidas no objeto dispensado pela ré e todos os demais elementos do contexto induzem à certeza da prática do delito.

Com efeito, o requisito subjetivo do tipo inexoravelmente deve ser demonstrado por meio de indícios (artigo 239 do Código de Processo Penal) e, quanto mais evidentes, maior a certeza. Isso porque se encontra no psíquico do agente e só é possível alcançá-lo (psíquico) avaliando os elementos objetivos (natureza e quantidade da droga, meio de acomodação, circunstâncias envolvendo a ação e prisão, conduta e antecedentes do agente, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006).

Ainda, não é plausível considerar o crime de posse de drogas para uso próprio como crime de bagatela, sendo impossível o reconhecimento da atipicidade material embasada no princípio da insignificância.

Ora, o fato tratado nos autos não é atípico, assim como a norma incriminadora prevista no artigo 28 da Lei de Tóxicos é absolutamente legal e regular, haja vista se tratar de crime de perigo abstrato e que tutela a saúde pública, atingindo toda a coletividade. Acerca do assunto:

POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. Pretendida declaração incidental da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Compatibilidade do dispositivo com a CF, que contém mandado de criminalização e severa repressão da circulação de drogas ilícitas. Precedentes. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Crime de perigo abstrato, com violação do bem jurídico presumida. Apelo improvido. (TJSP 16ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0006267-38.2017.8.26.0019. Relator: Des. Otávio de Almeida Toledo. Data do julgamento: 12 de maio de 2020)

Porte de drogas para consumo pessoal - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Insignificância - Impossibilidade independentemente da quantidade de drogas - O bem jurídico tutelado pela norma é a saúde pública e não apenas a do usuário - Recurso improvido. Artigo 28 da Lei 11.343/06 - Inconstitucionalidade - Não reconhecimento, uma vez que a norma penal permanece em vigor - Julgamento do E. Supremo Tribunal Federal suspenso. (TJSP 2ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0002358-88.2016.8.26.0482. Relator: Des. Klaus Marouelli Arroyo. Data do julgamento: 7 de maio de 2020)

Porte de entorpecentes para consumo próprio (art. 28, da L. 11.343/06). Absolvição na origem. Inaplicabilidade do art. 386, III, do Cód.Pr.Penal, para a espécie. Princípio da insignificância afastado. Lesão à saúde pública evidenciada, sem qualquer ofensa a princípios não positivados na legislação. Precedente. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Confissão em Juízo, ademais. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apelo ministerial provido. (TJSP 4ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 3001035-73.2013.8.26.0038. Relator: Des. Luís Soares de Mello. Data do julgamento: 12 de maio de 2015)

Ademais, por amor aos debates, cumpre salientar que não se verifica inconstitucionalidade no artigo 28 da Lei de Drogas, dispositivo legal que está em vigor, como também inexistente entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores acerca do assunto.

De fato, referido tipo penal não criminaliza o consumo do estupefaciente e, sim, o porte de droga para uso próprio, situação que coloca em risco a saúde pública e representa perigo social, tendo em vista a manutenção de entorpecentes em circulação na sociedade.

Ora, é de perigo abstrato o tipo penal do artigo 28 da Lei de Drogas, dispensando a produção de qualquer evento danoso, isto é, basta a prática da conduta típica,

sendo irrelevante, inclusive, se ínfima a quantidade de tóxico que o agente adquiria, guardava, tinha em depósito, transportava ou trazia consigo.

Destarte, a posse de droga para consumo pessoal ofende a coletividade, constituindo fato típico. Logo, não há se falar em atipicidade nem inconstitucionalidade do dispositivo.

Já no que se refere ao crime de resistência, há prova estreme de dúvidas no sentido de que a ré, depois da localização de estupefacientes no objeto por ela dispensado, resistiu à abordagem legalmente imposta pelos policiais militares e entrou em luta corporal com eles a fim de evitar sua contenção.

Outrossim, necessário acentuar que o chute desferido pela ré no peito do policial se deu quando ela já havia sido jogada ao chão e ele tentava algemá-la, e não no momento em que ambos ainda estavam em posição vertical.

Ademais, não se vislumbra nos informes dos ofendidos qualquer tentativa de prejudicar a ré, pois eles não teriam qualquer interesse em suscitar a atividade jurisdicional sendo que estavam exercendo sua profissão. Além disso, os fatos narrados pelos policiais militares comprovaram a necessidade de contenção da ré, a qual resistiu ao ato e se apresentou de forma bastante agressiva.

Vale destacar, quanto ao delito em análise, que a ré agiu dolosamente imbuída da "vontade livre e consciente de empregar violência contra o funcionário público ou ameaça, abrangendo o conhecimento de sua competência e da legalidade do ato visando impedir a realização do ato funcional" (DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS, Código Penal Anotado, 4ª ed., Saraiva, p. 841).

A jurisprudência consagra esse entendimento, que tem inteira aplicação na espécie:

"Sendo legítima a ordem de prisão dada ao Réu pelos policiais, opondo-se a ela, de forma violenta, comete o crime de resistência" (RT 433/430).

"Indivíduo que se opõe, mediante violência, à sua prisão. Efetivação desta preventivamente, a fim de evitar que agredisse a esposa e a sogra. Ordem legal. Condenação mantida. Inteligência do artigo 329 do CP. Embora não esteja alguém praticando infração alguma quando de sua prisão, justificando-se esta, porém, em caráter preventivo, face às contingências do momento, comete ele o delito de resistência se se opõe, com violência, à efetivação da custódia, causando ferimentos nos policiais" (RT 531/330).

Por derradeiro, é de fundamental importância salientar que a circunstância de a ré fazer uso de medicamentos não justifica a prática criminosa, nada havendo a demonstrar que, em razão disso, estivesse ela no momento dos fatos com a capacidade de entendimento e determinação alterada.

Dessa maneira, de rigor a condenação da ré também pelo delito de resistência.

Concluindo pela condenação da ré no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, no que toca à dosimetria da pena, destaco, de início, que as penas a serem aplicadas devem estar dentre aquelas previstas no tipo legal: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade ou comparecimento a programa ou curso educativo. Para a individualização da pena, no entanto, há que se verificar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, perfeitamente aplicável aos delitos previstos na Lei de Tóxicos. No caso em apreço, observo que a ré é reincidente (fls. 30/31: Execução da Pena nº 0029603-75.2018.8.26.0071, referente ao processo nº 0025997-78.2014.8.26.0071). Sendo assim, diante das circunstâncias do caso concreto, observada tal agravante, determino a aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 10 (dez) meses, nos termos do

disposto no artigo 28, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

No que se refere ao crime do artigo 329 do Código Penal, passo à dosagem da pena.

A culpabilidade da ré não merece maior reprovação, pois ficou estrita à prática do delito. A ré não ostenta antecedentes criminais, a não ser a reincidência a ser considerada em momento oportuno. Nada foi apurado sobre sua conduta social e sua personalidade, assim, reputo-as em seu favor. O motivo do crime é o comum. As circunstâncias e as consequências do delito não lhes são desfavoráveis. Por derradeiro, as vítimas não apresentaram comportamento relevante que influenciasse na dosimetria.

Destarte, inexistindo circunstância judicial contra a ré, fixo a pena no mínimo legal de 2 meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência (fls. 30/31: Execução da Pena nº 0029603-75.2018.8.26.0071, referente ao processo nº 0025997-78.2014.8.26.0071). Assim, por se tratar de reincidência específica, majoro a pena em 1/3, ficando, então, estabelecida no montante de 2 meses e 20 dias de detenção.

Na terceira fase da dosimetria, não há causa de aumento nem de diminuição a ser considerada, ficando mantida a sanção acima fixada, pena esta que torno definitivas em razão da ausência de outras causas modificadoras aplicáveis.

O regime inicial deverá ser o semiaberto (artigo 33, § 2º, "b" e "c", do Estatuto Repressivo).

Diante da reincidência, a ré não faz jus à substituição da pena corporal por restritiva de direitos nem à suspensão condicional da pena.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para CONDENAR a ré ANA PAULA CARVALHO à pena de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, por violação ao artigo 329, caput, do Código Penal, pena a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 10 (dez) meses, por violação ao artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, pena a ser definida pelo Juízo das Execuções, de acordo com as aptidões da ré, na forma do artigo 28, § 5º, da Lei de Drogas.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento e comunique-se à Vara de Execuções Penais, Instituto de Identificação e Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, III, da Constituição Federal).

A ré respondeu ao processo em liberdade. Além disso, não se vislumbram os requisitos autorizadores da prisão preventiva, de sorte que concedo a ela o direito de recorrer em liberdade.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Bauru, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA